

0000632-59.2017.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GELSON FRANCA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual GELSON FRANÇA DA SILVA, maior de 18 e menor de 21 anos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (fls. 96/97), eis ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

0000632-59.2017.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000632-59.2017.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GELSON FRANCA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual GELSON FRANÇA DA SILVA, maior de 18 e menor de 21 anos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (fls. 96/97), eis que, supostamente, no dia 20 de março de 2017, por volta das 14h20min, na Avenida Edmundo Amaral, na via pública, altura do nº 518, Piratininga, nesta cidade e Comarca de Osasco, trazia consigo e guardava drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, para fins de venda para consumo de terceiros, consistentes em 37 (trinta e sete) invólucros plásticos, tipo "ependorff", contendo cocaína, no total de 12g (doze gramas), 151 (cento e

cinquenta e uma) porções de cocaína na forma de "crack", no total de 67,95g (sessenta e sete gramas e noventa e cinco centigramas), conforme auto de exibição e apreensão a fls. 11, laudo de constatação de fls. 13/15, fotografias a fls. 12 e laudo de exame químico-toxicológico a ser oportunamente acostado.

Segundo se apurou, na data do ocorrido, policiais militares em diligências, abordaram o denunciado na via pública e, em revista pessoal, localizaram, no bolso de sua roupa, uma sacola plástica contendo a droga apreendida. Questionado, o denunciado alegou que estava apenas fazendo transporte daquela sacola até a Rua Niterói e que, pela atividade, receberia a quantia de R\$ 15,00 (quinze reais).

Pela forma de acondicionamento das drogas, pela quantidade e variedade de entorpecentes e pelas demais circunstâncias do fato criminoso, demonstrou-se que as drogas se destinavam à venda para consumo de terceiros.

O denunciado foi preso em flagrante conforme fls. 02. Às fls. 72/77 foi deferido ao réu o benefício da liberdade provisória cumulada com medidas cautelares.

Alvará de soltura cumprido às fls. 78.

Às fls. 99, foi determinada a notificação do acusado.

Após frustradas as tentativas para a notificação, em 06.02.2020 o processo foi suspenso nos termos do art. 366 do CPP (fls. 172).

Folha de antecedentes às fls. 335/338.

Laudo toxicológico definitivo às fls. 344/346.

O acusado foi notificado às fls. 327. Em defesa prévia apresentada às fls. 331/332 por intermédio da Defensoria Pública, reservou-se, a Defesa, o direito de se manifestar em momento oportuno.

Laudo Pericial às fls. 344/346.

Às fls. 347/349 foi revogada a revelia decretada às fls. 172. Nesta oportunidade, a denúncia foi recebida no dia 08 de abril de 2022 e a audiência de instrução, debates e julgamento virtual foi designada para o dia 31.08.2022, às 14h30.

Em audiência de instrução foi ouvida uma testemunha e o réu, ao final, interrogado.

Em debates, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da inicial.

Em debates, a Defesa requereu a absolvição. Sustentou inexistência de fundadas razões para abordagem, eis que afirmou o policial que o acusado demonstrou "nervosismo". Alegou que não é verossímil a afirmação de que o acusado teria aceito transportar a droga pelo valor de R\$ 15,00 reais. Alega que o acusado estava sozinho, sem denotar ato de tráfico. Não foi apreendida anotações. Em caso de condenação, requereu pena mínima, regime aberto e o redutor da menoridade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Com efeito, a finalidade epistêmica do processo penal é a busca da verdade, ainda que de forma aproximada, por meio de reconstrução fática que leve a superação do postulado da presunção de inocência e permita a imposição legítima de uma sanção penal. Entretanto, este objetivo teleológico deve ser buscado com respeito as

regras legais e constitucionais de produção e valoração das provas. Não é possível, dentro de um processo penal de fundamento democrático, a valoração da prova dissociada da ideia de legalidade. A legalidade da prova é pressuposto do juízo de mérito. O processo não é um fim em si mesmo e a verdade não pode ser buscada a qualquer custo, ainda mais havendo sacrifício de direito individual. Antes de qualquer valoração racional é sempre necessário o escrutínio da fonte legal da prova.

Nesse sentido: “assim, no Brasil, os códigos processuais, civil e penal, dispõem justamente acerca da validade da prova da verdade, que deverá seguir um trâmite que não cause surpresa às partes (livre acesso), que amplie sua participação no discurso relacionado ao seu enunciado (contraditório), que seja adequada e idônea ao fato que se quer provar e que não seja obtida por meios ilícitos. A busca da verdade não é, assim, orientada para a obtenção da verdade substancial, mas apenas da verdade provavelmente admitida. Não vigora mais, assim, no processo a busca da verdade real. Até porque, como já se disse, não existe essa suposta verdade real. Seria uma pretensão audaciosa do direito entender que o juízo possa fazê-lo unicamente pelos instrumentos legais.” (TAVARES, Juarez, CASARA, Rubens. Prova e verdade. 1ª ed. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2020, p. 147).

O Código de Processo Penal, saliente-se, adotou o sistema do livre convencimento objetivo motivado do juiz, pelo qual incumbe ao magistrado formar sua convicção a partir da livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, desde que fundamentadamente. Em outras palavras, não é lícito ao julgador formar sua convicção e, por conseguinte, proferir sentença condenatória com base em elementos colhidos ao arrepio de direitos individuais e de regras legais. O material probatório levado à análise judicial deve se revestir de legalidade, o que não se verifica no presente caso.

Inicialmente, anote-se que, conforme a única testemunha ouvida, o motivo que ensejou a busca pessoal foi que o acusado, ao ver as motocicletas da polícia militar, as quais realizavam patrulhamento de rotina, apresentou certo “nervosismo”. A testemunha não relatou qualquer outro motivo.

Com efeito, o simples nervosismo, sem qualquer elemento concreto, não é suficiente para concreção do standard probatório exigido pela lei - fundada suspeita - até porque não é incomum a qualquer pessoa - ainda mais em bairro periférico apresentar certo nervosismo diante de uma viatura policial ou mesmo de policiais armados (STJ - HC 659689-DF - Rel. Min. Sebastião Reis Junior - j. 15.06.2021 - 6ª T - Dje 18.06.2021).

Ainda: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA MOTIVADA APENAS POR IMPRESSÃO DE NERVOSISMO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A percepção de nervosismo do averiguado por parte de agentes públicos é dotada de excesso de subjetivismo e, por isso, não é suficiente para caracterizar a fundada suspeita para fins de busca pessoal, medida invasiva que exige mais do que mera desconfiança fundada em elementos intuitivos. 2. À falta de dados concretos indicativos de fundada suspeita, deve ser considerada nula a busca pessoal amparada na impressão de nervosismo do Acusado por parte dos agentes públicos. 3. Recurso especial provido, a fim de anular as provas obtidas ilicitamente, bem como as provas delas decorrentes e, em consequência, absolver o Recorrente, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. (STJ, REsp 1961459/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Data de Julgamento 05/04/2022, Dje 08/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS COM ORDEM CONCEDIDA. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA MOTIVADA APENAS POR IMPRESSÃO DE NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1. A despeito das alegações do agravante, não assiste razão, devendo ser mantida a decisão agravada. 2. No caso, não houve apresentação de fundada suspeita para revista pessoal no paciente, tendo os policiais apenas afirmado que notaram que o acusado revelou nervosismo ao avistar a guarnição e tentou esconder seu rosto. 3. A percepção de nervosismo do averiguado por parte de agentes públicos é dotada de excesso de subjetivismo e, por isso, não é suficiente para caracterizar a fundada suspeita para fins de busca pessoal, medida invasiva que exige mais do que mera desconfiança fundada em elementos intuitivos (Resp n.1.961.459/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022). 4. Agravo Regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 699.224/RS, 6ª Turma, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, Data de julgamento 17/05/2022, DJe 20/05/2022)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Nos termos do art. 240, §2º, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. No caso, os policiais faziam patrulhamento de rotina na região, ocasião em que visualizaram o paciente, o qual demonstrou nervosismo ao avistar a viatura policial. Foi então realizada a sua abordagem em local público, e, na busca pessoal, foram localizadas em seu poder porções de drogas que o acusado portava sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 3. Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida. 4. Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, devendo ser o paciente absolvido da imputação constante na denúncia. 5. Concessão do habeas corpus. Absolvição do paciente da imputação constante na denúncia. Expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso. (STJ, HC 722.175/SP, 6ª Turma, Min. Rel. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Data de julgamento 07/06/2022, DJe 10/06/2022)"

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA NO RÉU. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como aprova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida (HC 680.214/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 5/11/2021). 2. Na hipótese, não houve a indicação de nenhum dado concreto e objetivo sobre a existência de justa causa para autorizar a busca pessoal, visto que a simples existência de denúncia anônima sobre o deslocamento de pessoas para o local dos fatos no intuito de exercerem a venda de drogas, bem como o fato de que o suspeito aparentava suposto nervosismo diante da aproximação dos policiais (parâmetro subjetivo dos agentes policiais), não constituem fundamento idôneo para autorizar a busca pessoal, o que impõe o reconhecimento da ilicitude da prova obtida com a medida invasiva, bem como das provas dela derivadas. 3. Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AgRg no HC 706522/SP, 5ª Turma, Min. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, Data de julgamento 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

Portanto, ressoa dos autos a ilicitude originária da prova e, sendo esta a única a ensejar o flagrante, a absolvição é medida de rigor.

Por outro lado, não é demais asseverar que a declaração da testemunha não foi corroborada por nenhuma outra prova oral, até porque, conforme se depreende, a outra testemunha faleceu.

Saliente-se que não há gravação ou qualquer outro elemento indiciário que corrobore o depoimento do policial, fato este que, hodiernamente, poderia ser suprido com a gravação da bodycam.

Registre-se que não se está duvidando do depoimento do policial. Entretanto, nesta fase de valoração da prova a qualidade de policial, por si só, não infirma a prova ou a torna mais importante. Não é porque a pessoa é policial e que participou da ocorrência que sua versão ganha mais ou menos credibilidade. A credibilidade da versão apresentada deve ser valorada de forma racional de maneira a verificar se ela possui coerência interna e, ainda, se possui coerência externa quando corroborada com as demais provas apresentadas. No caso dos autos, como anotado, não há outras testemunhas e, ainda, não especificou o policial, com a precisão necessária, o contexto da abordagem, nem mesmo aludiu a qualquer ato de indicasse traficância ou até mesmo para o local no qual a droga seria levada.

Por fim, com razão a defesa pois não é crível que o acusado aceitasse realizar o transporte de droga, em quantidade não desprezível, como aponta a inicial, pela baixa quantia de R\$ 15,00. Assim, a versão do réu de que mora próximo, passava pelo local e que a droga teria sido encontrada em um terreno próximo não pode ser afastada, devendo, nesta senda, prevalecer o postulado da presunção de inocência.

Portanto, não logrou o Estado-acusação demonstrar suas premissas fáticas.

Nesse sentido, não foi possível o escrutínio da prova -em contraditório judicial - que levasse a uma reconstrução fática aproximativa das premissas afirmadas na inicial.

O direito penal, frise-se, não se contenta com conjecturas, nem mesmo com probabilidade de autoria. A moderna dogmática penal e processual penal exige a convicção plena do julgador, base ética indeclinável amparada em substrato material valorativo produzido em contraditório. Em outras palavras, a dúvida, por menor que seja, milita sempre em favor do acusado, eis que a presunção de inocência é corolário de um Estado de direito democrático.

Saliento, derradeiramente, que este juízo julga fatos praticados por pessoas e não pessoas independentemente de fatos. Assim, o fato do réu responder a outro processo em outro juízo, por outro Magistrado, não é suficiente (e não pode ser) para que este Magistrado interprete e valora os fatos de modo não racional-objetivo, mas sim de forma subjetiva, o que muito se aproximaria de um direito penal de autor, o qual, por essência, é antidemocrático. A condenação por outro juízo não gera presunção de culpa nestes autos.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e ABSOLVO o acusado GELSON FRANÇA DA SILVA, qualificado nos autos, da acusação de ter infringido o artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Determino a destruição dos entorpecentes.

Havendo bens apreendidos, não tendo sido reclamada a restituição, fica determinada liberação/destruição/leilão.

Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

PRIC

Osasco, 31 de agosto de 2022.